

刑法
No222

共通問題 R5-2

(配点：2)

月 日

月 日

暴行罪及び傷害罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものの個数を後記1から5までの中から選びなさい。

- ア. 相手方の眼前に抜き身の日本刀を突き付けたとしても、その刃が同人に接触しない限り、暴行罪が成立することはない。
- イ. 相手方の意思に反して、その耳元で楽器を大音量で鳴らし続けた場合には、人の身体に対して不法な攻撃を加えたものとして暴行罪が成立し得る。
- ウ. ひそかに相手方に睡眠薬を摂取させ、2時間にわたり意識を失わせるとともに筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせたとしても、覚醒後の健康状態に支障がない場合には、傷害罪が成立することはない。
- エ. 性病を有する者が、性行為を行えば相手方に感染させる危険性があると認識しながら、情を秘して同人と性行為を行い、同人に性病を感染させたとしても、同人が性行為に同意している場合には、傷害罪が成立することはない。
- オ. 相手方に暴行を加えて負傷させた者が、傷害結果が発生することについて認識を欠いている場合には、傷害罪が成立することはない。

1. 1個 2. 2個 3. 3個 4. 4個 5. 5個

No222	暴行罪及び傷害罪	正答率
共通R5-2	正解	57%
	4	

ア 誤っている

最決昭 39.1.28 (百選Ⅱ 3 事件) は、被告人が、被害者を脅すために、4 畳半の室内で抜き身の日本刀を数回振り回したという事案において、「原判決が、判示のような事情のもとに、狭い4 畳半の室内で被害者を脅かすために日本刀の抜き身を数回振り廻すが如きは、とりもおさず同人に対する暴行というべきである旨判断したことは正当である」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、暴行罪を処罰する趣旨は、被害者の身体を不当な有形力による侵害から保護しようとするところにあるため、被害者の五官に直接又は間接に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものである限り、ここにいう有形力に包含されると考えられ、そのような見地から、暴行は、必ずしも有形力が人の身体に接触することを要しないということを挙げている。よって、相手方の眼前に抜き身の日本刀を突き付けた場合、仮にその刃が同人に接触しなかったとしても、暴行罪 (208 条) が成立し得る。したがって、本記述は誤っている。

イ 正しい

最判昭 29.8.20 は、労働組合員である被告人らが、部課長らに対し、社長との団体交渉のあっせんをするように要求した際、同人らの身辺近くにおいてブラスバンド用の大太鼓などの楽器を連打したという事案において、「208 条にいう暴行とは人の身体に対し不法な攻撃を加えることをいう」とした上で、「被告人等が共同して判示部課長等に対しその身辺近くにおいてブラスバンド用の大太鼓、鉦等を連打し同人等をして頭脳感覚鈍り意識朦朧たる気分を与え又は脳貧血を起さしめ息詰る如き程度に達せしめたときは人の身体に対し不法な攻撃を加えたものであつて暴行と解すべきである」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、暴行罪における不法な有形力の行使の態様は、その手段・方法等によって多岐にわたり、音波・光線・熱・電気・臭気等のエネルギー的作用や毒物・病原菌・腐敗物・麻酔薬等による化学的作用も一種の物理力であつて、それが人体に対する不法な侵害と解される限り、いずれも広い意味の有形力として暴行概念に含まれるということを挙げている。よって、相手方の意思に反して、同人の耳で楽器を大音量で鳴らし続けた場合には、人の身体に対して不法な攻撃を加えたものとして、暴行罪 (208 条) が成立し得る。したがって、本記述は正しい。

ウ 誤っている

最決平 24.1.30 (百選Ⅱ 4 事件) は、被告人が、睡眠薬を混入させた洋菓子を被害者に提供し、又、同人の飲料に睡眠薬及び麻酔薬を混入させるなどして、これらを事情の知らない同人に飲食させたという事案において、「被告人は、病院で勤務中ないし研究中であつた被害者に対し、睡眠薬等を摂取させたことによって、約6 時間又は約2 時間にわたり意識障害及び筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせ、もって、被害者の健康状態を不良に変更し、その生活機能の障害を惹起したものであるから、いずれの事件についても傷害罪が成立する」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、本判例の事案は、起きていて活動中であつた被害者に対し、単なる失神 (脳の血流低下による一過性の意識消失) とは異なり、薬の薬理作用により、約6 時間あるいは約2 時間も持続する意識障害及び筋弛緩作用を生じさせたものであるところ、意識障害は脳の重要な機能が阻害されたものであるし、筋肉の弛緩という身体症状も生じているため、被害者の健康状態を不良に変更し、その生活機能の障害を惹起したものと認めるに十分であるということを挙げている。よって、相手方に睡眠薬を摂取させ、2 時間にわたり意識を失わせるとともに筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせた場合には、覚醒後の健康状態に支障がなかったとしても、傷害罪 (204 条) が成立し得る。したがって、本記述は誤っている。

エ 誤っている

最判昭 27.6.6 は、被告人が、病気の治療方法であるとして、被害者の承諾を得た上で同人に対して性行為を行った結果、性病を感染させたという事案において、「傷害罪は他人の身体の生理的機能を毀損するものである以上、その手段が何であるかを問はないのであり、本件のごとく暴行によらずに病毒を他人に感染させる場合にも成立する」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、傷害罪(204条)は、「人の身体を傷害した」場合に成立すると結果のみを規定し、その手段・方法を限定しておらず、物理的有形力の行使(暴行)のみならず無形的方法(暴行以外)による傷害罪も認められるということを挙げている。なお、肢イの解説でも述べたように、病原菌による化学的作用も一種の物理力であるため、病原菌に感染させるという行為も物理力の行使として暴行に当たるという見解もある。また、相手方は性行為には同意していても、性病の感染という身体傷害を承諾したという事情もない。よって、たとえ相手方が性行為に同意していたとしても、性病を感染させる危険性を秘して性行為を行い、結果的に性病を感染させた場合には、傷害罪(204条)が成立し得る。したがって、本記述は誤っている。

オ 誤っている

最判昭 25.11.9 は、被告人が、被害者に対し、大声で怒鳴り拳大の瓦の破片を投げつけ、更に「殺すぞ」等と怒鳴りながら鋏を振り上げて追いかけた結果、同人が転倒し傷害を負ったという事案において、「傷害罪は結果犯であるから、その成立には傷害の原因たる暴行についての意思が存すれば足り、特に傷害の意思の存在を必要としない」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、傷害罪は暴行罪との関係では結果的加重犯であるところ、重い結果を発生させる危険性を内包している犯罪行為を故意に行っている以上、責任非難は可能であることから、結果的加重犯の重い結果についてまで認識は不要であるということを挙げている。よって、傷害結果が発生することについて認識を欠いていたとしても、暴行の認識がある以上、傷害罪(204条)が成立し得る。したがって、本記述は誤っている。

以上により、誤っている記述はア、ウ、エ、オの4個であり、したがって、正解は肢4となる。